

<제3장 임금 제5절 휴업수당>

I. 서설

1. 의의[근기법 제46조 제1항]

- 휴업수당은 근로기준법 제46조 제1항에 규정된 바와 같이, 사용자의 귀책사유로 인하여 근로자가 휴업하는 경우에 사용자가 해당 근로자에게 지급해야 하는 임금 보전 금액을 말한다. 이는 근로자가 근로 제공 의사와 능력을 갖추고 있음에도 불구하고, 전적으로 사용자 측의 책임으로 근로를 제공하지 못하게 된 기간에 대하여 생계 유지를 위해 지급하는 것이다. 휴업수당은 근로의 대가로서의 임금이 아니라, 법정된 특수한 금품이다.

2. 취지

- 휴업수당 제도의 취지는 사용자의 경영 위험을 일부 분담시켜 근로자의 생계를 보장하고, 사용자의 자의적인 휴업을 억제하는 데 있다. 근로자는 사용자 측의 사정으로 근로 제공이 불가능해질 경우에도 최소한의 소득을 확보하여 경제적 어려움에 처하는 것을 방지해야 한다. 따라서, 휴업수당은 근로자 보호 강화를 목적으로 하는 강행규정적 성격을 갖는다.

II. 요건

1. 사용자의 귀책사유가 있을 것

- 휴업수당 지급 의무가 발생하기 위해서는 휴업의 원인이 사용자의 귀책사유에 있어야 한다.

(1) 귀책사유의 범위

- 여기서 귀책사유는 민법상 고의나 과실을 포함하는 개념을 넘어선다. 판례는 사용자의 세력 범위 내에서 발생한 모든 경영 상의 장애를 포함하는 광범위한 개념으로 해석한다. 예를 들어 원자재 부족, 시장 불황, 거래처 부도 등 사용자의 경영 사정 변동으로 인한 휴업 모두가 원칙적으로 사용자의 귀책사유에 해당한다. 다만, 천재지변, 전쟁 등 불가항력적인 사유로 인한 휴업은 귀책사유로 보지 않는다.

(2) 불가항력의 판단

- 불가항력으로 인정되기 위해서는 첫째, 원인 사태가 외부로부터 발생하였을 것, 둘째, 사용자가 최선의 노력을 다했음에도 불구하고 피해를 막을 수 없었을 것이라는 두 가지 요건을 충족해야 한다. 판례는 사용자에게 귀책사유가 없다는 것에 대하여 엄격하게 판단한다.

2. 휴업을 할 것

- 휴업수당 지급 요건으로서의 휴업은 근로자가 근로계약에 따라 근로 제공 의사와 능력을 가지고 있음에도 불구하고, 사용자의 귀책사유로 인하여 근로를 제공하지 못하는 상태를 의미한다.

(1) 휴업의 개념

- 여기서 휴업은 사업장 전체의 정지를 요구하는 것이 아니라, 개별 근로자가 근로 제공을 하지 못하는 상태로 포함하는 상대적 휴업의 개념이다. 전면적 휴업뿐만 아니라, 부분적 휴업, 즉 근로시간 단축으로 인한 휴업도 이에 해당한다.

(2) 근로자 측의 요건

- 휴업 기간 동안 근로자에게 근로 제공의 의사와 능력이 있어야 한다. 근로자 자신의 질병, 부상 등으로 인해 근로 제공이 불가능한 경우에는 휴업수당 지급 요건을 충족하지 못한다.

III. 휴업수당액

1. 휴업수당의 수준

- 근로기준법 제46조 제1항 본문은 사용자의 귀책사유로 휴업하는 경우에 사용자는 휴업기간 동안 그 근로자에게 평균임금의 100분의 70 이상의 수당을 지급하여야 한다고 규정한다.

(1) 산정 기준 및 지급 수준

- 휴업수당 산정의 기준이 되는 임금은 평균임금이다. 지급 수준은 평균임금의 100분의 70이 최소한의 하한선이며, 단체협약 등에서 그 이상을 정할 수 있다.

(2) 통상임금과의 관계

- 근로기준법 제46조 제1항 단서에는 평균임금의 100분의 70에 해당하는 금액이 통상임금을 초과하는 경우에는 통상임금을 휴업수당으로 지급할 수 있다.라고 규정한다.

2. 휴업기간 중 임금 일부를 지급받은 경우

- 휴업 기간 동안 사용자가 근로자에게 평균임금의 100분의 70에 미달하는 임금 등을 이미 지급한 경우에는, 그 지급액이 법정 휴업수당액에 미달하는 한도 내에서 차액만을 추가로 지급하면 된다. 예를 들어 사용자가 휴업 기간 동안 평균임금의 100분의 50을 지급했다면, 나머지 100분의 20을 추가로 지급해야 휴업수당 지급 의무를 이행한 것이 된다. 이는 법정 최저 수준을 보장하면서 기존 지급액을 유효하게 처리하기 위함이다.

IV. 휴업수당의 감액

1. 의의[근기법 제46조 제2항]

- 근로기준법 제46조 제2항은 부득이한 사유로 사업을 계속하는 것이 불가능하여 노동위원회의 승인을 받은 경우에는 기준에 못 미치는 휴업수당을 지급할 수 있다.라고 규정한다. 이 규정은 사용자의 책임 범위를 넘어선 부득이한 사유가 발생하여 사용자에게 과도한 부담을 줄 때, 예외적으로 휴업수당 지급 의무를 완화하기 위한 것이다.

2. 감액지급의 요건

- 휴업수당을 감액 지급하기 위한 요건은 엄격하다.

(1) 부득이한 사유가 있을 것

- 부득이한 사유를 천재지변이나 그 밖에 불가항력적인 사유로 판단하는 견해가 있으나, 해당 사업 외부의 사정에 기인하여 사용자의 세력 범위 내에서 발생한 사유로 판단하는 것이 타당하다. 판례는 구체적인 사정을 고려하여 감액지급의 요건 충족 여부를 판단하고 있다.

(2) 노동위원회의 승인을 받을 것

- 사용자는 휴업수당 감액 또는 면제를 위해 사전에 노동위원회의 승인을 받아야 한다. 노동위원회는 부득이한 사유의 존재 여부, 근로자 생활 보장 필요성 등을 종합적으로 고려하여 승인 여부와 감액 수준을 결정한다. 이러한 승인 절차는 사용자의 일방적인 권리 남용을 방지하기 위함이다.

3. 감액의 정도

- 휴업수당의 감액 정도는 노동위원회가 승인 할 때 정한다. 노동위원회는 사용자의 재정 상태, 휴업의 규모, 기간, 근로자의 생활 정도 등을 고려하여 감액 비율을 결정한다. 판례는 근로기준법 제46조 제2항은 사용자의 휴업지불의무의 예외를 정한 것이고, 그러한 예외의 경우에 휴업지불의 하한이 별

도로 정해져 있지 않은 이상 사정에 따라서는 사용자가 휴업지불을 전혀 하지 않는 것도 가능하다고 볼 수 있다라고 판시한다.

V. 기타 관련 문제

1. 부분파업과 휴업수당

- 부분파업은 근로자의 쟁의행위 기간이므로, 원칙적으로 휴업수당 지급 요건인 근로 제공 의사 및 능력이 부정되어 휴업수당 지급 의무가 발생하지 않는다. 파업 기간은 근로자 측의 귀책사유로 인한 근로 제공 정지에 해당한다. 다만, 파업 이후 사용자가 경영 상의 이유로 일부 부서 등에 대하여 정상적인 근로 제공을 수령하지 않고 휴업을 시키는 경우에는, 그 부분에 대해서는 사용자의 귀책사유가 인정되어 휴업수당 지급 의무가 발생할 수 있다.

2. 직장폐쇄와 휴업수당

- 직장폐쇄는 사용자의 방어적 쟁의행위로서, 적법한 직장폐쇄 기간 동안에는 근로자의 노무에 대한 사용자의 수령 거부가 적법하게 인정되어 사용자의 귀책사유가 부정된다. 따라서, 적법한 직장폐쇄 기간에는 휴업수당 지급 의무가 발생하지 않는다. 그러나, 직장폐쇄가 방어적 수단으로서의 정당성을 잃고 공격적 수단으로 변질되거나 위법한 직장폐쇄로 판단되는 경우에는, 사용자의 귀책사유가 인정되어 휴업수당 지급 의무가 발생할 수 있다.

3. 민법상의 임금지급청구와 휴업수당

- 사용자의 귀책사유로 인한 휴업 시, 근로자는 근로기준법상 휴업수당(평균임금의 70%) 외에도 민법 제538조 제1항의 채권자 지체 책임 규정에 따라 손해배상으로서 임금 전액(100%)을 청구할 수 있다. 휴업수당은 법정된 최소한의 보상 수준이므로, 근로자가 실질적인 임금 손실(통상 임금 전액 수준)을 입증하여 민법상 채무불이행 책임을 물어 청구하는 것은 가능하다. 다만, 휴업수당 청구권과 민법상 임금 청구권은 경합관계에 있으므로, 휴업수당 지급액을 초과하는 손해(평균임금 70%를 초과하는 부분)에 대하여만 추가로 청구할 수 있다.

4. 중간수입과 휴업수당

- 휴업 기간 동안 근로자가 다른 사업장에 취업하여 임금 등 소득(중간수입)을 얻은 경우, 사용자는 그 중간수입 금액을 휴업수당에서 공제할 수 있다. 근로기준법 제46조의 휴업수당 규정에는 중간수입 공제에 대한 명시적 규정이 없으나, 해고예고수당 규정 등 유사 규정의 취지를 유추 적용하여 인정된다. 다만, 공제 가능한 중간수입 금액은 평균임금의 70%를 초과하는 금액에 한정하여 공제하는 것이 타당하다는 것이 다수설의 입장이다. 즉, 휴업수당액은 공제 후에도 최소한 평균임금의 70% 수준을 보장해야 한다.

VI. 결론

- 휴업수당은 사용자의 귀책사유로 인한 휴업 시 근로자의 생계를 보장하기 위한 법정 수당으로, 평균임금의 100분의 70 이상을 지급해야 한다. 휴업수당 지급 의무를 감액하거나 면제하려면 부득이한 사유 및 노동위원회의 승인이라는 엄격한 요건이 필수적이다. 휴업수당은 민법상 임금 전액 청구권과는 경합 관계에 있으며, 근로자가 휴업 기간 중 얻은 중간수입은 일정 범위 내에서 공제 가능하다.